

2. 案由：竞业限制纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):甲服务公司

被告(被上诉人):耿某

【基本案情】

甲服务公司的经营范围包括代理记账等,耿某系该公司的办税人员。2022年4月29日,耿某与甲服务公司办理工作交接,甲服务公司向耿某出具《员工离职证明》。2022年4月28日,乙服务公司成立,经营范围包括代理记账等。耿某于2022年5月25日成为该公司的办税人员。2022年7月29日,甲服务公司向耿某支付竞业限制补偿费6300元。

庭审中,甲服务公司举示了一份《知识产权保护及竞业禁止协议》,约定竞业期限自离职之日起到离职后两年,甲服务公司每月支付竞业限制补偿费,连续三个月未支付,则视为协议自动终止;如耿某违反协议,应立即停止违约,并继续履行本协议,并向甲服务公司支付惩罚性违约赔偿金300000元。该协议尾部乙方处耿某签字并按指印,落款时间为2022年2月1日,甲方处加盖的公章名称为“甲服务公司”。

另查明,2022年6月6日甲服务公司由曾用名更名为“甲服务公司”,“甲服务公司”的公章系2022年6月6日之后启用。

甲服务公司申请仲裁后诉至法院,诉称耿某离职后即入职新公司,违反了《知识产权保护及竞业禁止协议》,故请求耿某继续履行《知识产权保护及竞业禁止协议》中约定的竞业限制义务,以及支付竞业限制违约金300000元并返还竞业限制补偿6300元。

【案件焦点】

《知识产权保护及竞业禁止协议》是否成立。

【法院裁判要旨】

重庆市渝北区人民法院经审理认为:《知识产权保护及竞业禁止协议》并

未成立。第一，甲服务公司将《知识产权保护及竞业禁止协议》（此时双方均未签字）交与耿某，2022年2月1日耿某签字后将该协议交还公司，公司即应在合理期限内做出承诺，承诺的具体表现为在协议上盖章并返还给耿某或通过其他有效方式（如履行主要义务等）表示公司已接受了该协议的约束。第二，耿某于2022年4月29日办理离职手续，距其向甲服务公司提交《知识产权保护及竞业禁止协议》已有三个月，而劳动者享有自主择业的权利，竞业限制义务势必对劳动者离职后的自主择业产生限制，用人单位拖延承诺的行为将影响劳动者的就业权，故甲服务公司应至迟在劳动者离职时即2022年4月29日将耿某需遵守的竞业限制义务及相应权利进行固定、明确并以特定形式告知耿某。而根据庭审查明事实，耿某离职时，甲服务公司并未在协议上签章，也未通过其他有效方式告知耿某，故甲服务公司与耿某并未就履行《知识产权保护及竞业禁止协议》达成合意。第三，因甲服务公司在《知识产权保护及竞业禁止协议》签章的行为发生于2022年6月6日之后，超出合理承诺期限，其行为应视为新的要约，现无证据证明耿某对该新的要约进行了确认。甲服务公司虽于2022年7月29日向耿某转账支付竞业限制补偿费，但耿某也表示不予接受，故亦无法认定此时双方就履行《知识产权保护及竞业禁止协议》达成合意。第四，甲服务公司与耿某并未就履行竞业限制义务达成合意，对于甲服务公司要求耿某履行《知识产权保护及竞业禁止协议》并按该协议约定支付违约金的诉讼请求不予支持。对于甲服务公司已支付的竞业限制补偿费，因耿某获得无依据，应当返还，对于返还竞业限制补偿的诉讼请求应予以支持。

重庆市渝北区人民法院判决如下：

- 一、耿某于本判决生效之日立即返还甲服务公司补偿费6300元；
- 二、驳回甲服务公司的其他诉讼请求。

甲服务公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第一中级人民法院同意一审法院裁判意见。

重庆市第一中级人民法院按照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十

七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

目前，实践中存在竞业限制对劳动者泛化适用的问题，部分本不必要承担竞业义务的劳动者不得不受到竞业协议的限制。这与竞业限制制度的立法要旨相悖。因此，对竞业限制协议的司法认定具有重要现实意义。

一、离职竞业限制以存在竞业限制协议为前提

我国现行法律仅承认在雇佣双方劳动关系终止后基于约定而形成竞业限制特定权利义务关系，质言之，离职后的竞业限制以用人单位与劳动者存在竞业限制约定为限。

如当事人要求高级管理人员、董事等一般劳动者承担竞业限制义务，则须以双方签订离职竞业限制协议或在劳动合同中约定离职竞业限制条款为前提，否则当事人的主张缺乏依据。本案中，甲服务公司举示了一份《知识产权保护及竞业禁止协议》，故审查的关键是判断该协议是否成立。

二、离职竞业限制协议合意的司法价值判断

我国现行合同成立规则系统形成于《中华人民共和国民法典》合同编通则合同的订立一章，通常认为“承诺生效时合同成立”为一般原则，合同书情形下“双方签字盖章时”或“当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时”是相对于该原则的例外。

司法实践中，往往需要综合运用前述合同成立的裁判规则对要约和承诺的意思表示进行解释，以探究当事人真意。其中不仅包含大量事实判断，更包含裁判者对事实作出的价值判断。离职竞业限制协议的底层逻辑契约自由原则与劳动关系的鲜明的从属性之间存在冲突，相较于用人单位，劳动者通常处于天然弱势地位，但《中华人民共和国劳动合同法》始终是以保护劳动者的合法权益为其宗旨，这就要求司法者在法律适用层面，正确把握价值秩序以对个案进行判断，通过合目的性解释以弥补立法之不足。

(一) 离职竞业限制协议要约的认定

首先，甲服务公司将未盖章的竞业限制协议交给耿某的行为不应认定为要约。虽然甲服务公司提供的竞业限制协议明确、具体，但事后可以证实甲服务公司此时并未在该协议上进行盖章，即便经耿某签字后，该协议仍具有甲服务公司不予盖章的可能性，故甲服务公司提供竞业限制协议的行为并不包含经受要约人承诺即受要约约束的意思，不宜认定为要约。

与此相对应，耿某在竞业限制协议上签字并交还公司的行为应认定为要约。耿某在具体、明确的竞业限制协议上签字并交还协议的行为应认定为认可协议内容、希望与甲服务公司订立协议并愿意受该协议约束的意思表示，故该行为应视为要约。此时，对于耿某的要约，甲服务公司可以通过两种方式予以有效回应并以此促成竞业限制协议的合法成立。一是根据《中华人民共和国民法典》第四百八十一条规定，在合理期限内作出承诺并将该承诺告知耿某；二是根据《中华人民共和国民法典》第四百九十条第二款规定，履行竞业限制协议的主要义务并经耿某接受。

(二) 离职竞业限制协议承诺的认定

对于第一种方式，核心在于认定甲服务公司作出竞业限制协议承诺的合理期限。对于耿某的竞业限制协议要约，甲服务公司应迟于耿某离职之时作出承诺并告知耿某，否则将使耿某离职后的就业陷入不确定之状态，从而限制耿某的择业自由，影响耿某劳动权的行使。

对于第二种方式，核心在于判断甲服务公司是否履行竞业限制协议的主要义务并经耿某接受。本案中，竞业限制协议约定甲服务公司应按月支付竞业限制补偿，然公司却于耿某离职后三个月才向其支付首笔补偿费，故甲服务公司难谓有通过履行主要合同义务对合同成立瑕疵进行补正的主观意图，公司的行为不能视为有效承诺。

综上，法院认定甲服务公司与耿某并未形成离职竞业限制的合意，该认定既符合当前合同成立的判断规则，亦有助于让竞业限制制度回归本位，遏制当前竞业限制协议的滥用趋势。

应从竞业限制到期日计算经济补偿金的仲裁时效起算点

——吴某诉某科技公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终10237号民事判决书

2. 案由: 劳动争议

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人): 吴某

被告(反诉原告、被上诉人): 某科技公司

【基本案情】

吴某原系某科技公司员工。2016年9月15日, 某科技公司(甲方)与吴某(乙方)签订的《保密协议》第二条第五项约定: “乙方离开甲方公司后, 应遵守竞业禁止的规则。除非得到甲方的书面认可, 否则乙方在二年内不得在同类的产业中任职, 更不能向同类产业的其他单位和个人提供甲方的商业秘密与技术, 亦不得有任何通过第三人的变相违约行为。” 某科技公司通知吴某于2021年4月14日解除劳动合同, 未通知吴某不用履行竞业限制的内容, 吴某之后申请了劳动仲裁要求某科技公司支付违法解除劳动合同赔偿金。吴某主张2020年4月至2021年3月月均工资7150元。某科技公司主张吴某月均工资6500元。自2021年8月起, 北京市最低工资标准变更为2320元。吴某主张2021年4月14日后未从事竞业限制的相关行业。2022年9月15日, 吴某向某区劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁申请, 要求某科技公司支付2021年4月15

日至2023年4月14日竞业限制补偿金55680元。2023年2月22日仲裁委作出 裁决：一、某科技公司自裁决生效之日起十五日内，支付吴某2021年9月15日至2023年2月14日竞业限制经济补偿39440元；二、驳回吴某的其他仲裁 请求。吴某与某科技公司均不服该裁决，遂提起本案诉讼。

【案件焦点】

吴某主张离职后竞业限制经济补偿金的劳动仲裁的仲裁时效应从何时起算。

【法院裁判要旨】

北京市石景山法院经审理认为：劳动争议申请仲裁的时效期间为一年，2021年9月15日前吴某要求支付竞业限制补偿的仲裁请求已过时效，该院不予支持。现，双方未约定解除或者终止劳动合同后给予经济补偿，故某科技公司应支付吴某2021年9月15日至2023年4月14日竞业限制经济补偿44080元。

北京市石景山区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条，参照《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第三十六条，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某科技公司于判决书生效之日起十五日内，支付吴某2021年9月15日至2023年4月14日竞业限制经济补偿44080元；

二、驳回吴某的其他诉讼请求；

三、驳回某科技公司的全部诉讼请求。

吴某不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：本案的二审争议点为，吴某提出的由某科技公司支付2021年4月14日至9月15日的竞业限制经济补偿金的主张是否超过仲裁时效。竞业限制补偿系基于劳动者履行竞业限制义务应获得的报酬性补偿。某科技公司与吴某签订的《保密协议》并未约定劳动关系解除或终止后的竞业限制补偿的支付标准和期限，且某科技公司未履行支付竞业限制补偿金义务处于持续、连续状态。《中华人民共

和民法典》第一百八十九条规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。参照此规定，考虑到竞业限制补偿金的性质，自竞业限制履行期届满之日起计算仲裁时效，更利于保护劳动者的权利，也更为公平。故，吴某在竞业限制履行期限届满后一年内主张竞业限制补偿，不应认定超过仲裁时效。鉴于吴某在一审中提出诉讼请求，要求某科技公司支付2021年4月15日至2023年4月14日的竞业禁止补偿金，一审判决后，某科技公司未对此提出上诉，故对于吴某主张的竞业禁止补偿金的支付期间予以确认。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持北京市石景山区人民法院(2023)京0107民初7976号民事判决第三项；

二、撤销北京市石景山区人民法院(2023)京0107民初7976号民事判决第二项；

三、变更北京市石景山区人民法院(2023)京0107民初7976号民事判决第一项为：某科技公司于本判决书生效之日起十五日内，支付吴某2021年4月15日至2023年4月14日的竞业限制经济补偿55680元。

【法官后语】

因用人单位未支付竞业限制补偿金发生的劳动仲裁，可以分为两种情况：第一种是用人单位与劳动者明确约定了一次性支付补偿金的情况下，时效起算点应以约定的支付期限之日计算仲裁时效，对此理论界和司法实践中均无异议。第二种是用人单位与劳动者约定按月支付补偿金的情况下，如何认定仲裁时效起算点法律没有明确规定，司法实践中存在两种不同的观点：第一种观点认为，竞业限制经济补偿金应按月分别计算仲裁时效起算点。第二种观点认为，竞业限制经济补偿金应从竞业限制到期日计算仲裁时效起算点，即从最后一期竞业限制补偿金应支付之日开始计算仲裁时效。本案采纳了第二种观点，理由如下。

1. 从利益平衡原则角度分析，竞业限制制度既要保护用人单位的商业秘密权，也要保护劳动者的劳动权。《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条规定，对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。司法实践中，用人单位通过与劳动者签订竞业限制协议的方式，来达到保护商业秘密利益的目的，但不可避免地会损害劳动者的劳动权和自由就业权，而竞业限制经济补偿金的功能之一就在于平衡劳动双方利益，补偿劳动者因遵守竞业限制而牺牲的劳动权和自由就业权。故，由于用人单位一方违约，未及时向劳动者支付经济补偿金的情况下，不应苛责劳动者就此向用人单位履行过高的提示义务，亦不应由劳动者因用人单位的违约而承担不利的法律后果。

2. 从最后一期竞业限制补偿金应支付之日开始计算仲裁时效，更有利于保护劳动者诉权利益和节约司法成本。《中华人民共和国劳动合同法》第二十四条第二款规定，在解除或者终止劳动合同后，竞业限制期限不得超过二年，即竞业限制期限最长为劳动合同解除后二年，而《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第一款规定的劳动者申请仲裁时效为一年。基于此，司法实践中常出现劳动者在解除劳动合同后1~2年申请仲裁的情况，此时，竞业限制期尚未结束，而劳动合同解除已满一年。如果按月分别计算仲裁时效，劳动者需要尽到较高的注意义务，警惕诉权过期，至少应提起二次仲裁申请才能避免超仲裁时效。反之，如果以竞业限制期届满之日计算仲裁时效，则可以有效避免上述情况。

3. 参考《中华人民共和国民法典》第一百八十九条规定，按月支付竞业限制经济补偿金可视为连续的债务履行行为。该条明确规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。本案涉及的按月支付竞业限制经济补偿金，是用人单位与劳动者约定按月支付经济补偿金，从劳动合同解除或终止后按月定期发放，直至竞业限制期限届满为止，且每一期竞业限制补偿金均是基于同一竞业限制协议而连续产生，故可以视为连

续的同一债务分期履行行为。因此，从法律逻辑和技术性判断上而言，支付竞业限制经济补偿金也应参照该条规定，从最后一期竞业限制补偿金应支付之日起开始计算仲裁时效。

编写人：北京市第一中级人民法院 孙沙沙
尹佳雯

六、社会保险

54

工伤认定中“因履行工作职责受到暴力伤害”的认定

——王某某诉某区人民政府改变原行政行为的行政复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省高级人民法院(2022)赣行终268号行政判决书

2. 案由：行政复议

3. 当事人

原告(被上诉人):王某某

被告:某区人民政府

第三人(上诉人):某科技公司

第三人(被上诉人):某区人力资源和社会保障局

【基本案情】

廖某原系S乡某村路段的环卫工人。2020年6月廖某在从事环卫工作时未完成任务,被作为S乡片区专管员的王某某发现。王某某将此事上报给公司,并导致廖某工资被扣。廖某遂对王某某心怀不满,于2020年11月2日对正在S

①入库案例,参见人民法院案例库2024-12-3-016-004。

乡某村巡查环卫工作的王某某实施殴打，导致王某某肋骨骨折。2020年11月3日，某区公安局作出行政处罚决定，廖某因该殴打行为被处以行政拘留五日的处罚。2021年3月15日，王某某以某科技公司为工作单位向某区人力资源和社会保障局（以下简称某区人社局）申请认定工伤。2021年5月25日，某区人社局作出工伤认定决定，认定王某某在本次事故中造成的伤害，符合《工伤保险条例》第十四条第三项的规定，同意认定为工伤。某科技公司不服该工伤认定决定，遂向某区人民政府（以下简称某区政府）申请行政复议。2021年9月22日，某区政府作出行政复议决定，认为王某某肋骨骨折系原环卫工人廖某因私人恩怨对其殴打导致，非因工作原因或履行工作职责导致，不能认定为工伤，决定撤销某区人社局作出的工伤认定决定。王某某不服该行政复议决定，向江西省上饶市中级人民法院提起行政诉讼。

【案件焦点】

王某某被殴打受伤是否属于因履行工作职责受到暴力伤害。

【法院裁判要旨】

江西省上饶市中级人民法院经审理认为：王某某被殴打受伤属于因履行工作职责受到暴力伤害，符合《工伤保险条例》第十四条第三项规定，应当认定为工伤。

江西省上饶市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第八十九条之规定，判决如下：

- 一、撤销被告某区政府于2021年9月22日作出的《行政复议决定书》；
- 二、恢复第三人某区人社局于2021年5月25日作出的法律效力。

某科技公司不服一审判决，提起上诉。江西省高级人民法院经审理认为：综合案涉工伤认定决定、被诉行政复议决定、原审判决认定及各方当事人的辩解意见，本案争议的主要焦点是王某某被殴打受伤是否属于因履行工作职责受到暴力伤害。《工伤保险条例》第十四条第三项规定：“职工有下列情形之一的

的，应当认定为工伤……（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的……”按照上述规定，职工受到的暴力伤害与履行工作职责有因果关系的，应当认定职工受到的暴力伤害属于因履行工作职责受到暴力伤害。进言之，因果关系作为一种客观存在，如果已认定职工受到的暴力伤害系因履行工作职责引起，在没有证据证明存在其他引发暴力侵害因素的情况下，不能仅以暴力侵害发生的时间具有滞后性没有当场发生为由否定该因果关系的存在。简言之，不能仅以暴力侵害行为具有滞后性而否定因果关系的客观存在。本案中，根据某区公安局对廖某作出的《行政处罚决定》等证据材料，廖某系因2020年6月其在从事环卫工作时未完成任务被作为S乡片区专管员的王某某发现并上报公司导致其工资被扣一事对王某某怀恨在心，遂于2020年11月2日对正在S乡某村巡查环卫工作的王某某实施了殴打。据此，应认定王某某受到的暴力伤害与履行工作职责存在直接因果关系，属于因履行工作职责受到暴力伤害。因此，王某某在其负责的S乡某村巡查环卫工作时被廖某殴打受伤，属于在工作时间和工作场所内因履行工作职责受到暴力伤害，符合《工伤保险条例》第十四条第三项规定的情形，应当认定为工伤。某区政府既已认定廖某殴打王某某的原因是，王某某作为专管员在2020年6月的工作管理行为致廖某工资被扣怀恨在心所致，但在没有证据证明王某某与廖某存在其他私人恩怨的情况下，某区政府仅以廖某的暴力侵害没有于2020年6月当场发生而是发生在2020年11月2日为由，主张王某某被殴打受伤系因私人恩怨，不属于因履行工作职责受到暴力伤害，进而认为王某某的受伤因不符合《工伤保险条例》第十四条第三项的规定不能认定为工伤，缺乏事实和法律依据。因此，法院以某区政府作出的行政复议决定适用法律错误为由撤销该行政复议决定，符合法律规定。

江西省高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《工伤保险条例》及原劳动和社会保障部就“因履行工作职责受到暴力”

作出了相关规定，但实践中对于是否应当适用《工伤保险条例》第十四条第三项的规定认定工伤仍存在争议。关于暴力伤害与履行工作职责有因果关系的认定，应以原因力大小为判断依据，即应以暴力伤害与履行工作职责之间的关联性是否足以达到认定工伤的程度为标准。具体而言，应从“履行工作职责”要素出发，综合考量是否存在其他因素及其各因素原因力的大小，着重审查以下三个主要方面：

一是暴力伤害的本源性因素。判断暴力伤害与履行工作职责是否具有直接因果关系，核心的本源性因素在于工作原因是否为引发暴力伤害的主要原因。如果工作原因是引发暴力伤害的主要原因甚至为唯一原因，则应认定暴力伤害与履行工作职责之间具有直接因果关系，属于“因履行工作职责受到暴力”的情形。如果能够证明暴力伤害系因职工故意或严重过失造成，或者职工对暴力伤害后果的发生负有主要责任，抑或其他介入因素导致原本属于工作原因的关联性中断，则不宜认定职工所受暴力伤害与履行工作职责具有直接因果关系，不应认定为工伤。

二是暴力伤害的阶段性因素。从行为过程看，工伤认定中职工所受暴力伤害亦具有阶段性，具体可分为受伤起因、受伤过程以及受伤结果三个阶段。一般而言，三个阶段均需与履行工作职责相关。从受伤起因看，引发暴力伤害的原因应为工作原因，如果暴力伤害系因个人恩怨引发，则不能认定为“因履行工作职责”。从受伤过程看，需要判断是否有介入因素中断因果关系，如果即便受伤起因与履行工作职责有关，但过程中存在诸如第三人劝说调停、对方主动停息等中断因果关系的因素介入后，职工自己再次主动挑起纠纷并受到伤害，则不宜认定系因履行工作职责受到暴力伤害。从受伤结果看，需要综合判断各因素的原因力大小，如果工作原因是主要原因，即便职工个人存在一定过错，也不宜否定暴力伤害与履行工作职责之间的直接因果关系。

三是暴力伤害的时空性因素。现实生活中，因履行工作职责引发并遭受的暴力伤害经常会存在时间上的滞后性。关于暴力伤害发生的滞后性是否必然阻却职工受到的暴力伤害与履行工作职责之间的直接因果关系，实践中存在不同观点。第一种观点认为，直接因果关系属于近因，要求暴力伤害须当场发生，

方可认定暴力伤害与履行工作职责之间具有直接因果关系。第二种观点认为，直接因果关系虽为近因，但该近因系强调原因力的大小而非强调时间上的远近，只要工作原因是引发职工在工作时间和工作场所内受到暴力伤害的主要原因，即便暴力伤害发生具有一定的滞后性，亦不必然阻却职工受到的暴力伤害与履行工作职责之间的直接因果关系。第三种观点认为，只要职工系因履行工作职责受到他人暴力伤害，即便不是发生在工作时间和工作场所内，也应当认定为工伤。笔者认为，本案判决采取的第二种观点，更加符合立法本意。一般而言，在没有确切证据证明职工存在引发暴力侵害的其他个人因素情况下，不宜仅以暴力侵害没有当场发生即暴力侵害的发生具有滞后性为由，而否定职工受到的暴力伤害与履行工作职责存在直接因果关系。如果职工过错系一般过失，则不应中断工伤因果关系的认定，且不适用过失相抵原则。首先，应审查职工个人行为是否超出了用人单位所能支配与控制的范围。即围绕是否系从事本职工作、超过本职工作范围是否系为了维护用人单位利益等方面进行审查。其次，应审查职工个人行为是否改变履职行为的性质。如果能够证明暴力伤害系因职工故意或严重过失造成，或者职工对暴力伤害的发生负有主要责任，则意味着职工个人过错行为已改变其履职行为的性质，或是已切断暴力伤害与履行工作职责之间的关联性，该情形下即便职工个人行为起因于履职行为，亦不应认定暴力伤害与履行工作职责之间具有直接因果关系。

综上所述，本案中，王某某作为卫生专管员，于2020年11月2日在工作巡查时被廖某殴打受伤。根据《行政处罚决定》等在案证据显示，王某某遭受廖某殴打系因工作原因。法院结合上述暴力伤害的考量因素分析认定，虽然王某某所受暴力侵害，与其检查上报环卫工作之间时隔数月之久，但王某某受到的暴力伤害符合本源性、阶段性、时空性要素特点，与履行工作职责存在直接因果关系，属于“因履行工作职责受到暴力”的情形。

编写人：江西省高级人民法院

万进福 南昌铁路运输

法院 熊娇娇

第三人侵权的工伤事故中已判赔 但未执行到位的重复项目赔偿款不应抵扣

——熊某诉鲜某工伤保险待遇案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2024)沪01民终2693号民事判决书

2. 案由：工伤保险待遇纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):熊某

被告(上诉人):鲜某

【基本案情】

熊某原在某物流公司工作。2019年12月1日,熊某在送货途中发生交通事故,当日至2020年1月13日,熊某在医院住院治疗,住院天数43天。2019年12月,某物流公司向医院预交住院费合计215000元。2020年6月23日,上海市浦东新区人民法院受理了熊某与王某、某家纺公司、某土方公司、甲保险公司、乙保险公司、丙保险公司机动车交通事故责任纠纷一案[案号:(2020)沪0115民初41956号]。2020年8月26日,上海市浦东新区人民法院作出民事判决:……四、王某、某家纺公司对熊某医疗费298984.20元、住院伙食补助费860元合计299844.20元中的207034.94元承担连带赔偿责任。2020年12月25日,上海市奉贤区人民法院作出民事判决,确认熊某与某物流公司于2018年3月17日至2019年12月1日存在劳动关系。之后,某物流公司提起上诉,

上海市第一中级人民法院作出民事判决，驳回上诉，维持原判。2021年1月11日，上海市浦东新区人民法院受理了熊某与王某、某家纺公司、某土方公司、甲保险公司、乙保险公司、丙保险公司机动车交通事故责任纠纷一案[案号：(2021)沪0115民初7592号]。2021年9月2日，上海市浦东新区人民法院作出民事判决：……四、王某、某家纺公司连带赔偿熊某213813.15元……2021年2月25日，上海市浦东新区人民法院作出(2020)沪0115执26763号执行裁定，以被执行人王某、某家纺公司现名下无可供本案执行的财产等为由终结(2020)沪0115民初41956号案件的执行。2021年7月7日，由鲜某签字的全体投资人承诺书递交给了工商登记部门。2021年8月16日，某物流公司被注销。2022年8月8日，上海市浦东新区人民法院作出(2022)沪0115执10219号执行裁定，以穷尽财产调查措施，本案被执行人王某、某家纺公司暂无财产可供执行，故无继续执行的条件，应终结(2021)沪0115民初7592号案件的执行。2023年1月31日，熊某以鲜某、某物流公司作为被申请人向上海市奉贤区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。2023年2月2日，上海市奉贤区劳动人事争议仲裁委员会作出不予受理通知书，对上述请求决定不予受理。熊某不服，遂诉至上海市奉贤区人民法院。

【案件焦点】

熊某在侵权案中已判赔但未执行到位的重复项目赔偿款是否在工伤保险待遇案中予以抵扣。

【法院裁判要旨】

上海市奉贤区人民法院经审理认为：根据法律规定，在第三人侵权引起工伤事故的情形下，会产生工伤保险赔偿与第三人侵权损害赔偿竞合。除兼得项目外，对于重复赔偿项目应采用“就高原则”。本案中，(2021)沪0115民初7592号民事判决书认定熊某的损失中，除保险公司赔付外，由被执行人王某、某家纺公司赔付的部分，根据(2022)沪0115执10219号执行裁定书，因暂无财产可供执行，无继续执行的条件，故终结执行程序。因此，熊某所主张的误

工费、护理费(除保险公司已赔付外)等重复赔偿项目实际未获赔偿,在此情形下,熊某通过工伤途径寻求救济,并承诺今后在机动车交通事故责任纠纷案件中若获得赔付,愿意将本案中获得的赔付款退还给鲜某,其要求鲜某赔付的请求合理,法院依法予以支持。在法院判决后至鲜某实际赔付之前,熊某若从被执行人王某、某家纺公司处获赔,则获赔的部分可予以抵扣。

上海市奉贤区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十条第一款、第四十四条第五项、第四十六条第六项、第四十七条第一款及第三款,《工伤保险条例》第三十条第四款、第三十三条、第三十七条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第二十条,《上海市工伤保险实施办法》第三十一条第一款、第四十一条第一款、第五十八条第二款、第六十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定,判决如下:

一、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某第一次住院伙食补助费人民币430元;

二、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某劳动能力鉴定费人民币350元;

三、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某停工留薪期护理费人民币6417元(若熊某另从被执行人王某、某家纺公司处获赔,则获赔金额予以抵扣);

四、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某停工留薪期工资人民币60000元(若熊某另从被执行人王某、某家纺公司处获赔,则获赔金额予以抵扣);

五、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某病假工资人民币160.92元;

六、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某一次性伤残补助金人民币63228元;

七、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某一次性工伤医疗补助金人民币93042元;

八、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某工伤一次性伤残就业补助金人民币93042元;

九、鲜某于判决生效之日起十日内赔偿熊某经济补偿人民币17500元;

十、驳回熊某的其余诉讼请求。

鲜某不服一审判决，提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为，鲜某的上诉请求是否成立。鉴于现有证据表明判决并未得到履行，本案中一审判决鲜某支付护理费及停工留薪期工资，并判决若熊某从另案中获赔则予以抵扣，判决正确。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

在工伤保险赔偿和民事侵权损害赔偿竞合的情况下，工伤职工同时享有两种救济方式，从而产生工伤保险赔偿和第三人侵权损害赔偿的交叉。具体赔偿项目是“兼得”还是“就高”，目前法律并没有统一规定。当工伤职工在侵权损害赔偿之诉中已判赔但未实际获赔，转而通过工伤途径寻求救济时，重复项目赔偿款是否予以抵扣，仍存在一定争议，但无论是从损失填平原则还是从保护劳动者合法权益原则，在侵权案中已判赔但未执行到位的重复项目赔偿款应不予抵扣。

一、第三人侵权的工伤事故中的责任竞合

在第三人侵权引起工伤事故的情形下，工伤保险赔偿案件与第三人侵权损害赔偿案件产生竞合，会产生两种赔偿请求权：一是工伤职工的工伤保险赔偿请求权；二是工伤职工向第三人提起的侵权损害赔偿请求权。两种请求权的权利基础和归责原则不同，工伤保险赔偿请求权基础是劳动者因发生工伤事故获得的一种社会保险利益，工伤保险赔偿实行无过错责任原则，有社会保险性质；而第三人侵权损害赔偿请求权基础是劳动者因第三人侵权致害而取得，侵权损害赔偿实行的是民法的填平原则、过错原则和过失相抵原则，侵权损害赔偿的损失包括财产性损失及非财产性损失，其性质属于私法领域的赔偿。

二、工伤损害赔偿责任和民事侵权责任竞合的解决模式

（一）兼得、选择以及补充模式

工伤损害赔偿责任和民事侵权责任竞合的解决模式主要有以下三种：兼得

模式、选择模式以及补充模式。

兼得模式允许工伤职工在请求侵权赔偿的同时享受工伤保险待遇，获得“双方利益”。这种模式下对劳动者十分有利，尤其是在工伤保险待遇和民事赔偿标准偏低的情况下，可使工伤职工获得充分赔偿，但这种模式下违反了填平原则，即受害人不应因被侵权而获益，并加重了工伤保险基金和用人单位负担。

选择模式允许工伤职工在侵权损害赔偿和工伤保险赔偿之间自由选择一种，往往能获得较高的赔偿数额，但也往往受制于赔付方的赔偿能力。

补充模式是指民事侵权赔偿和工伤保险待遇互相补充，基于工伤保险赔偿和侵权损害赔偿所得的数额不超过实际损失。这种模式一方面避免了工伤职工获得双份利益，节省了工伤保险基金的和用人单位的支出；另一方面保证受害人获得完全的赔偿。

（二）重复项目就高赔偿原则

第三人侵权引起工伤事故中应将受害劳动者可获得的赔偿项目划分为三类：第一类是定额赔偿项目，如工伤保险赔偿中的一次性伤残补助金及侵权损害赔偿中的残疾赔偿金等赔偿项目，对于这类项目应允许受害劳动者兼得；第二类是专属赔偿项目，包括残疾津贴等专属于工伤保险赔偿的项目及营养费等专属于侵权赔偿的项目，这类项目是工伤保险赔偿和侵权损害赔偿所各自特有的项目，应当允许权益遭受侵害的职工在两种救济途径当中分别主张，使其权益得到更加全面的保护；第三类是其他财产性的重复赔偿项目，如工伤保险赔偿中的原工资福利待遇和侵权损害赔偿中的误工费等费用，这些费用是工伤职工在维护自身合法权益时实际花费的费用，如果允许其同时获得两份赔偿，则有悖于民法中的填平原则，因此对于第三类赔偿项目不允许权益受侵害的职工享有同时获得双份赔偿的权利，对于此类项目应采用“就高”原则，即针对二者间相同并重复的赔偿项目，按照各自的计算标准，最后在二者之间选取数额较高的作为权益受侵害劳动者应当获赔的数额。

（三）工伤保险机构(用人单位)享有追偿权原则

《工伤保险条例》的立法目的是保护工伤劳动者及时得到赔偿，只要工伤

一经认定，工伤保险经办机构即给予相应的保险待遇，是一项及时有效的救济。但不排除当事人考量民事侵权赔偿的金额更高，或是侵权人偿付能力等情况而优先选择侵权损害赔偿。

就重复项目获得重复赔偿的，用人单位或工伤保险经办机构可以在扣除按照就高原则确定的劳动者应获得的赔偿数额后的剩余部分对第三人进行追偿，但其追偿的数额不得超过其实际支付的重复赔偿项目的总数，也不得高于第三人的实际赔偿限额。

三、未实际获赔情形下重复项目赔偿款应不予抵扣

（一）损失填平原则

损失填平原则是我国民事赔偿中的基本原则之一，是以弥补权利人的实际损失为目的，也称为补偿性赔偿，其核心理念是侵权人或违约人承担其行为造成的全部损失赔偿责任，以实现公平正义和维护社会经济秩序。损失填平应遵循两个基本原则：一是损失的数额在填补之前是确定的；二是通过填补至填平，使权利人在经济上的损失完全消失。第三人侵权导致的工伤事故中，若重复项目在工伤保险赔偿中未实际获赔，则被侵权人的损失未得到弥补，若再请求侵权损害赔偿，从损失填平原则来说，应予以支持，不予抵扣。反之亦然。

（二）保护劳动者合法权益原则

《中华人民共和国劳动合同法》的立法宗旨是“双保护”前提下的偏向劳动者合法权益。对于劳动者在第三人侵权的工伤事故中已判赔但未执行到位的重复项目赔偿款，从保护其合法权益原则角度考虑，不予抵扣符合立法本意。

另需要说明的是，为了更好地平衡当事人的权益以及避免诉累，若在工伤保险赔偿的判决作出之后至法律文书生效前有部分执行或执行到位的，则在文书中直接明确该部分可予抵扣；若在法律文书生效后，在工伤保险赔偿中获得了重复项目赔偿款，之后再从侵权案中获赔的，则由劳动者在判决前明示同意对重复项目获赔款项予以返还。

编写人：上海市奉贤区人民法院 张晓燕
胡小琴

工伤员工仲裁期间死亡，
用人单位是否仍须支付“三个一次性”补助金
——某保安公司诉王某乙工伤保险待遇案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终2894号民事判决书

2. 案由：工伤保险待遇纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某保安公司

被告(被上诉人):王某乙

【基本案情】

王某甲于2019年11月9日入职某保安公司从事保安工作，月工资2300元，未签订劳动合同，未缴纳社会保险。2019年11月19日，王某甲下班途中发生交通事故受伤，后未再到某保安公司工作。2022年1月，桓台县人力资源和社会保障局作出《认定工伤决定书》，认定王某甲构成工伤。某保安公司不服，经过行政复议、行政诉讼一审、二审，最终工伤认定予以维持。2022年9月，淄博市劳动能力鉴定委员会作出《劳动能力鉴定结论书》，认定王某甲劳动功能障碍程度为八级，无生活自理障碍。2023年1月，王某甲作为申请人以某保安公司为被申请人向淄博市劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求确认与某保安公司自2019年11月20日至2023年1月17日存在劳动关系、2023年1月18日解除劳动关系，并要求某保安公司支付一次性伤残补助金、一次性工

伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金(以下简称“三个一次性”补助金), 停工留薪期工资等。但未等到仲裁裁决作出, 王某甲于2023年2月因病死亡, 继承人王某乙参加仲裁。仲裁委于2023年3月作出仲裁裁决: 王某甲与某保安公司自2019年11月20日至2023年1月17日存在劳动关系, 于2023年1月18日解除劳动关系, 某保安公司支付王某甲继承人王某乙解除劳动关系经济补偿金8050元、停工留薪期工资13800元、一次性伤残补助金38491.20元、一次性工伤医疗补助金58320元、一次性伤残就业补助金93312元。某保安公司辩称, 王某甲已因病去世, 不存在医疗和就业的可能, 且“三个一次性”补助金具有专属性, 故无须再向王某甲遗属履行支付义务, 因而诉至法院。

【案件焦点】

工伤员工仲裁期间死亡, 用人单位是否仍须支付“三个一次性”补助金。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市张店区人民法院经审理认为: 王某甲于诉讼前死亡, 依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十五条规定, 王某乙作为王某甲继承人参加本案诉讼, 主体适格。

关于某保安公司与王某甲之间劳动关系存续期间的确认。案涉仲裁裁决确认王某甲与某保安公司自2019年11月20日至2023年1月17日存在劳动关系, 并驳回了王某甲的其他仲裁请求。上述仲裁申请系为认定工伤提出, 工伤认定书生效后, 王某甲所受伤害为工伤, 依法享有停工留薪期等工伤保险待遇, 依据《工伤保险条例》第三十七条的规定, 劳动合同期满终止或者职工本人提出解除劳动合同的, 劳动关系解除。本案中, 双方并未签订劳动合同, 故不存在劳动合同期满的问题。按照《山东省工伤职工停工留薪期管理办法》《山东省

《工伤保险停工留薪期分类目录》的规定，王某甲因工作遭受事故伤害后应当享受6个月的停工留薪期。按照《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》第二十一条第二款“工伤职工在停工留薪期内，除法律规定的情形外，用人单位不得与其解除或终止劳动关系”的规定，虽然王某甲自2019年11月19日工伤后

未再到某保安公司工作，某保安公司作为用工单位，负有对职工的管理权，故王某甲停工留薪期届满，某保安公司应当行使管理权。但至王某甲2023年1月18日提起仲裁前，某保安公司并未解除与王某甲的劳动关系，双方劳动关系应当延续。王某甲在仲裁申请之日提出解除劳动关系，依据上述法律规定，应认定某保安公司与王某甲自2019年11月20日至2023年1月17日存在劳动关系，于2023年1月18日解除劳动关系。对某保安公司关于王某甲重复仲裁的抗辩，不予认可。

关于解除劳动合同经济补偿及停工留薪期工资。王某甲以某保安公司未依法为其缴纳社会保险费为由解除劳动关系，并要求某保安公司支付解除劳动关系经济补偿的请求，符合法律规定，支持经济补偿8050元($2300\text{元/月} \times 3.5\text{个月}$)。王某甲要求支付的停工留薪期工资13800元($2300\text{元/月} \times 6\text{个月}$)，符合法律法规规定，予以支持。关于“三个一次性”补助金。王某甲因工作遭受事故伤害后被认定为工伤，劳动功能障碍程度为八级，某保安公司未参加工伤保险，故某保安公司应当按照《工伤保险条例》第六十四条，《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》第二十五条的有关规定支付王某甲一次性伤残补助金38491.20元($5832\text{元/月} \times 60\% \times 11\text{倍}$)；一次性工伤医疗补助金58320元($5832\text{元/月} \times 10\text{个月}$)；一次性伤残就业补助金93312元($5832\text{元/月} \times 16\text{个月}$)。

关于某保安公司主张王某甲去世后不存在继续医疗和就业的可能，其无须支付一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的问题。首先，从法律性质上看，王某甲亲属主张的一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金赔偿均是基于法律的直接规定，从请求权产生的时间点来看，一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金自王某甲与某保安公司解除劳动关系时产生，即在王某甲死亡前已经产生，之所以没有支付是因为双方发生争议并多次进入仲裁、复议、诉讼等程序。其次，从继承法律规范的角度看，继承是将死者生前的财产和其他合法权益转归有权取得该项财产的人所有的法律制度，《中华人民共和国继承法》第三条规定，遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产性权

利。本案中，王某甲死亡前已产生的前述待遇属于其合法财产性权利，属于可继承的财产，一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金虽具有人身专属性，但并非绝对不能继承，在它转化为特定的财产权利后可以继承，故前述工伤保险待遇并不会随着王某甲的死亡而消灭。最后，允许工伤职工的继承人继承工伤保险待遇符合公平正义的理念。工伤职工受到事故伤害的同时，其家庭和近亲属实际上同样受到伤害，包括职工受伤导致其家人减少或丧失生活来源以及增加额外支出费用。如果在工伤职工死亡后待遇就随之消灭，那么对于工伤职工和其家庭来讲，显然不符合公平原则。综上，虽然王某甲在诉讼前死亡，但其工伤保险待遇在其死亡前均已产生并确定，故不能免除某保安公司应支付工伤保险待遇的法定义务，且王某乙作为王某甲的继承人，有权向某保安公司主张包括一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金在内的工伤保险待遇。

山东省淄博市张店区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十八条、第四十六条、第四十七条，《工伤保险条例》第三十三条、第三十七条、第六十四条，《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》第二十一条、第二十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五十五条的规定，判决如下：

一、确认原告某保安公司与王某甲在2019年11月20日至2023年1月17日存在劳动关系；

二、确认王某甲于2023年1月18日与原告某保安公司解除劳动关系；

三、原告某保安公司于本判决生效之日起十日内支付王某甲继承人被告王某乙解除劳动关系经济补偿金8050.00元；

四、原告某保安公司于本判决生效之日起十日内支付王某甲继承人被告王某乙停工留薪期工资13800.00元；

五、原告某保安公司于本判决生效之日起十日内支付王某甲继承人被告王某乙一次性伤残补助金38491.20元；

六、原告某保安公司于本判决生效之日起十日内支付王某甲继承人被告王某乙一次性工伤医疗补助金58320.00元；

七、原告某保安公司于本判决生效之日起十日内支付王某甲继承人被告王某乙一次性伤残就业补助金93312.00元；

八、驳回原告某保安公司的其他诉讼请求。

某保安公司不服一审判决，提起上诉。山东省淄博市中级人民法院同意一审法院的裁判意见。

山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

工伤保险待遇中的“三个一次性”补助金请求权的基础均是基于法律的直接规定，虽具有一定的人身专属性，但并非绝对不能继承，在转化为特定的财产性权利后可以继承，并不会随着工伤职工的死亡而消灭。允许工伤职工的继承人继承工伤保险待遇符合公平正义的理念，可有效防止部分用人单位恶意利用仲裁、诉讼程序拖欠工伤保险待遇，且有利于弘扬诚实守信的社会主义核心价值观。

工伤保险待遇中，“三个一次性”补助金是指一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金，是劳动者遭受工伤或者患职业病后，依据《工伤保险条例》规定的条件依法享有的经济赔偿。工伤职工被依法确定伤残等级后，由工伤保险基金支付一次性伤残补助金。工伤职工被鉴定为五级至十级伤残，在劳动关系解除或者终止时，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。若用人单位未缴纳工伤保险，则“三个一次性”补助金均由用人单位支付。

工伤职工因其他疾病死亡或者意外死亡，其继承人是否可以继承其生前应当享受的工伤保险待遇？一种观点认为，工伤保险待遇具有人身专属性，该民事权利随着工伤职工的死亡而消亡，不能继承；另一种观点认为，继承人可以继承工伤职工生前应当享受的工伤保险待遇，允许工伤职工的继承人继承工伤保险待遇符合公平正义的理念。笔者同意第二种观点。实际上，工伤职工受到

事故伤害的同时，其近亲属乃至整个家庭同样遭受伤害，特别是因伤致残的，主要表现为家庭劳动力的削弱、收入的减少甚至生活来源的丧失、高额费用的额外支出等。如果工伤职工死亡后待遇随之消灭，实践中可能会出现用人单位恶意拖欠工伤保险待遇的情形，不利于督促用人单位及时承担企业责任。若用人单位否认劳动关系、否认工伤、否认各项工伤待遇数额，就每一问题均穷尽了诉讼程序，拖延履行支付工伤保险待遇的法定义务，导致工伤职工直至去世都没有获得待遇支付，用人单位因工伤职工死亡而免除上述义务，对工伤职工及其家属来说是显失公平的。

从法理的角度讲，“三个一次性”补助金请求权的基础均是基于法律的直接规定，在工伤职工死亡前已经产生，之所以没有支付是因为双方发生争议并多次进入仲裁、复议、诉讼等程序。工伤职工的死亡不应影响这三项待遇的支付。从继承的角度讲，继承是将死者生前的财产和其他合法权益转归有权取得该项财产的人所有的法律制度。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十二条第一款规定，遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。本案中，王某甲死亡前已产生的“三个一次性”补助金等工伤保险待遇，虽具有人身专属性，但并非绝对不能继承，在转化为特定的财产性权利后，可以继承，并不会随着王某甲的死亡而消灭。因此，法院判决维护了王某甲及其遗属的合法权益。

实践中，劳动争议案件的诉讼成本较低，部分用人单位会利用一、二审程序甚至执行程序恶意拖延履行单位义务，导致劳动者被动累诉。本案的典型意义在于肯定工伤保险待遇不会因为工伤职工的死亡而消灭，用人单位仍应向其继承人支付工伤保险待遇，弘扬公平正义、诚实守信的社会主义核心价值观。

编写人：山东省淄博市张店区人民法院胡卿

交通事故与工伤竞合时，劳动者能否获得双重赔偿

——某机械公司诉肖某2劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省郴州市中级人民法院(2023)湘10民终2561号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人):某机械公司

被告(被上诉人):肖某2

【基本案情】

2021年3月，毛某以食堂厨师身份入职某机械公司，负责员工餐饮等工作，约定月工资2300元。其间，某机械公司未为毛某缴纳工伤保险费。2021年11月28日17时15分许，毛某步行途经一十字路口时发生交通事故，当场被送往医院抢救，后于同年11月29日0时28分因重度颅脑外伤经该院抢救无效死亡。

事故发生后，肇事者李某赔偿肖某250000元，肇事者李某犯交通肇事罪，被判处有期徒刑一年四个月。湖南省嘉禾县人民法院作出(2022)湘1024民初977号民事判决：由李某赔偿肖某2(曾用名肖某1，系死者毛某之子)因交通事故致毛某死亡产生的损失635804元。

2022年1月12日，嘉禾县公安局交通警察大队作出《道路交通事故认定书》，认定毛某在此次交通事故中负次要责任。肖某2向郴州市人力资源和社

会保障局申请对毛某认定工伤，该局作出《认定工伤决定书》，认定毛某受到的事故伤害，符合《工伤保险条例》第十四条第六项之规定，属于工伤认定范围，现予以认定为工伤。某机械公司就该工伤保险资格认定向湖南省桂阳县人民法院提起行政诉讼，要求对毛某不予认定工伤，该院作出(2022)湘1021行初221号行政判决：驳回某机械公司的诉讼请求。某机械公司不服该判决提起上诉，湖南省郴州市中级人民法院作出(2023)湘10行终15号行政判决：驳回上诉，维持原判。

2023年2月26日，肖某2向嘉禾县劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁请求：裁定由被申请人对申请人之生母毛某因工亡依法应获得补助金1008240元承担给付申请人肖某2的义务。同年6月19日，嘉禾县劳动人事争议仲裁委员会作出仲裁裁决：一、由被申请人某机械公司支付申请人肖某2丧葬补助金37062元、一次性工亡补助金876680元，共计913742元整。上述款项于本裁决生效之日起十五日内给付。二、驳回申请人的其他仲裁请求。

【案件焦点】

交通事故与工伤竞合时，劳动者能否获得双重赔偿。

【法院裁判要旨】

湖南省嘉禾县人民法院经审理认为：用工单位招用已超过法定退休年龄或者已享受退休待遇的人员而发生的争议不属于劳动争议。本案中，毛某出生于1963年8月16日，2021年3月入职某机械公司时已超过法定退休年龄，因此某机械公司与毛某之间不属于劳动关系。根据《最高人民法院关于超过法定退休年龄的进城务工农民在工作时间内因公伤亡的，能否认定工伤的答复》明确指出：“用人单位聘用的超过法定退休年龄的务工农民，在工作时间内、因工作原因伤亡的，应当适用《工伤保险条例》的有关规定进行工伤认定。”本案中，毛某的伤亡已经生效法律文书认定为工伤，依法应享受工伤保险待遇。其近亲属应享受的工伤保险待遇包括丧葬补助金、一次性工亡补助金。《中华人民共和国社会保险法》第四十一条规定：“职工所在用人单位未依法缴纳工伤

保险费,发生工伤事故的,由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的,从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的,社会保险经办机构可以依照本法第六十三条的规定追偿。”《工伤保险条例》第三十九条规定:“职工因工死亡,其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金……(三)一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍……”毛某的一次性工亡补助金应为876680元(43834元/年×20倍)。故,肖某2要求某机械公司支付一次性工亡补助金876680元的诉请,于法有据,法院依法予以支持。其要求支付丧葬费的诉请,因法院生效民事判决书已作出判决,故该项诉请,法院不予支持。因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害,构成工伤的,劳动者因工伤事故享有工伤保险赔偿请求权,因第三人侵权享有人身损害赔偿请求权,二者虽然基于同一损害事实,但存在两个不同的法律关系之中,互不排斥。劳动者具有工伤事故中的伤亡职工和人身侵权的受害人的双重主体身份,有权向用人单位主张工伤保险赔偿,同时也有权向侵权人主张人身损害赔偿,不因基于其中一种身份先行获得一方赔偿,实际损失已得到全部或部分补偿而免除或减轻另一方的责任。某机械公司诉称与毛某不存在劳动关系,且已向肇事者主张权利,其请求判令无须向肖某2支付毛某死亡赔偿金的诉讼请求,与法相悖,法院不予支持。

湖南省嘉禾县人民法院依照《中华人民共和国社会保险法》第四十一条,《工伤保险条例》第三十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条之规定,判决如下:

一、某机械公司向肖某2支付毛某因工死亡的一次性工亡补助金876680元,限判决生效之日起十五日内付清;

二、驳回肖某2的其他仲裁请求。

某机械公司不服一审判决,提起上诉。湖南省郴州市中级人民法院经审理认为:本案的争议焦点为,某机械公司应否向肖某2支付毛某的一次性工亡补助金876680元。本案中,毛某已被人力资源社会保障部门认定为工伤,某机械

公司不服该行政行为提起行政诉讼后，一、二审法院均维持了人力资源社会保障部门对毛某作出的工伤认定决定，并驳回了某机械公司要求撤销对毛某的工伤认定决定的诉讼请求。工伤认定属于行政决定的一种，行政决定一经作出即发生法律效力，在未经法定机关和法定程序撤销或变更之前，对行政相对人和其他利害关系人均具有法律约束力。毛某已被相关的行政机关认定为工伤，根据工伤认定决定的性质，其应当享受相应的工伤保险待遇。《中华人民共和国社会保险法》第四十一条规定：“职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的，社会保险经办机构可以依照本法第六十三条的规定追偿。”《工伤保险条例》第三十九条规定：“职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金……（三）一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍……”肖某2要求某机械公司支付毛某的一次性工亡补助金876680元符合法律规定，某机械公司提出其不向肖某2支付毛某的一次性工亡补助金的上诉请求无事实和法律依据，法院不予支持。侵权法律关系与工伤保险法律关系属于两种不同的法律关系，被侵权人获得侵权赔偿不影响企业应承担的社会保险责任，某机械公司提出肖某2已获得侵权赔偿，不应再获得工伤赔偿的上诉理由不能成立，法院不予支持。综上所述，某机械公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

湖南省郴州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《工伤保险条例》第十四条规定：“职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：……（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道

交通、客运轮渡、火车事故伤害的……”从该条可以看出：一个交通事故的侵权行为同时触发了两个法律关系，一是受害人与肇事人之间的侵权赔偿法律关系；二是劳动者与用人单位之间的工伤赔偿法律关系。此在法律上称为竞合。那么，司法实务中，应如何把握交通事故与工伤竞合的赔偿规则？对直接费用（医疗费、护理费、残疾用具费、住院伙食补助费）能否重复赔偿？误工费与停工留薪期工资是否属于重复赔偿项目？因现行法律法规及政策并无明确规定，实践中存在不同观点。

一、关于交通事故与工伤竞合时，劳动者是否能够获得双重赔偿

交通事故侵权赔偿与工伤保险待遇，两者虽基于同一损害事实，但法律性质不同、法律关系不同、法律规范不同、承担责任主体不同，并行不悖，受害方可以获得“双重赔偿”。这是目前司法实务界的普遍观点。关于双赔依据，劳动者因交通事故导致工伤，工伤的劳动者存在两个请求权，一个是基于工伤保险关系而享有的工伤保险请求权；另一个是基于人身损害而享有的民事侵权损害赔偿请求权。依据为：（1）《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：“依法应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者，因工伤事故遭受人身损害，劳动者或者其近亲属向人民法院起诉请求用人单位承担民事赔偿责任的，告知其按《工伤保险条例》的规定处理。因用人单位以外的第三人侵权造成劳动者人身损害，赔偿权利人请求第三人承担民事赔偿责任的，人民法院应予支持。”（2）《最高人民法院关于因第三人造成工伤的职工或其亲属在获得民事赔偿后是否还可以获得工伤保险补偿问题的答复》规定：“因第三人造成工伤的职工或其近亲属，从第三人处获得民事赔偿后，可以按照《工伤保险条例》第三十七条的规定，向工伤保险机构申请工伤保险待遇补偿。”（3）《中华人民共和国社会保险法》第四十二条规定：“由于第三人的原因造成工伤，第三人不支付工伤医疗费用或者无法确定第三人的，由工伤保险基金先行支付。工伤保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。”（4）《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第八条第二款规定：“职工因第三人的原因受到伤害，社会保险行政部门已经作出工伤认

定，职工或者其近亲属未对第三人提起民事诉讼或者尚未获得民事赔偿，起诉要求社会保险经办机构支付工伤保险待遇的，人民法院应予支持。”笔者认为，从上述规定中可以看出，劳动者因第三人原因遭到事故伤害，不因受害方先行获得一方全部或部分赔偿而免除或减轻另一方的责任，且不分先后。

二、第三人赔偿的误工费与工伤保险待遇中的停工留薪期是否属于重复赔偿项目

实务中，在交通事故赔偿中误工费与工伤保险待遇中的停工留薪工资确实存在重合的情况，是否可以双重赔偿存在不同观点。

观点一认为，可以双重赔偿。理由如下：一是《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第八条第三款规定：“职工因第三人的原因导致工伤，社会保险经办机构以职工或者其近亲属已经对第三人提起民事诉讼为由，拒绝支付工伤保险待遇的，人民法院不予支持，但第三人已经支付的医疗费用除外。”该条仅规定不支持医疗费的双重赔偿，并不包含误工费。二是误工费与停工留薪期间工资的概念、性质、计算标准均不同，不属于重复请求，亦不属于实际发生费用。比如，河北省高级人民法院(2018)冀民申2867号民事裁定认为：“因第三人侵权导致工伤的，劳动者在向侵权人主张人身损害赔偿后，是否还可以向用人单位主张工伤赔偿问题，现行法律对此没有明确的禁止性规定，故申请人主张本案属于重复赔偿，缺乏法律依据。停工留薪期间工资与误工费不是同一个法律概念，不存在重复赔偿。”

观点二认为，不可双重赔偿。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条规定：“误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定……受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算……”上述规定表明，第三人赔偿误工费是以受害人“实际减少的收入”的事实为前提，因此受害人不能因为一个损害行为获得重复利益，如果已经从侵权方或者工伤保险中的一方待遇获得误工足额赔偿的，不应支持其他方的赔偿，尚未获得足额赔偿的，可支持其他方补足差额。

三、第三人已经赔偿的医疗费、护理费、残疾用具费、住院伙食补助费，劳动者能否要求双赔

医疗费不可双赔，在司法实务中没有争议。但对于护理费、残疾用具费、住院伙食补助费在实务中依然存在两种不同观点。一是认为可以双重赔偿，理由如上文所述；二是认为不可双重赔偿，认为根据人身损害赔偿“损失填平”以及不能因同一损害而获得法外利益的法律原则，对于直接损失以及重复(竞合)项目，如护理费、交通费、住院伙食补助费、被抚(扶)养人生活费等费用不支持双重赔偿。

工伤保险与民事赔偿的性质不同，适用法律不同，不能相互替代，劳动者的工伤系第三人侵权所致，对于劳动者先获得侵权赔偿的，不影响其享受工伤保险待遇。但对于医疗费不得重复享有。例如，四川省高级人民法院(2018)川民再787号民事判决认为：“工伤保险待遇与侵权赔偿责任竞合时，如劳动者执行任务时因第三人原因受伤，一方面可依据侵权行为法向侵权人请求损害赔偿；另一方面可依据工伤保险条例请求保险给付，两者请求权基础不同，归责原则和权利的保护范围不同，互不排斥；因第三人造成工伤的职工或其近亲属，从第三人处获得民事赔偿后，可以按照《工伤保险条例》第三十七条的规定，向工伤保险机构申请工伤保险待遇补偿，第三人已经支付的医疗费用除外。所以除医疗费等直接费用外，劳动者可以在有限范围获得双重赔偿。”笔者认为，因第三人造成的工伤，可以获得除医疗费外的双重赔偿，即民事赔偿与工伤赔偿可以双赔，不分先后，但医疗费不能双赔。

编写人：湖南省嘉禾县人民法院 李志东

用人单位违法解雇孕期女职工应赔偿生育津贴损失

—— 张某诉某科技公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2023)渝01民终7708号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(上诉人): 张某

被告(被上诉人): 某科技公司

【基本案情】

张某于2015年4月1日在某科技公司会员管理二部工作, 2021年1月6日, 某科技公司成立, 张某于同日被调至某科技公司工作, 并与该公司签订劳动合同。张某工作期间, 单位依法为其办理了社会保险。2021年3月, 张某怀孕。2021年12月16日, 某科技公司作出《解除(终止)劳动关系证明书》称张某于2021年12月16日因违反公司规章制度被公司辞退, 张某已按公司规定办理完毕离职手续, 双方劳动关系已于2021年12月16日依法解除。张某于2022年1月6日申请劳动仲裁, 请求某科技公司支付工资、房屋销售佣金、违法解除劳动关系赔偿金、生育津贴损失等。张某于2022年1月28日分娩顺利生产。诉讼中, 张某未举示生育医疗费用的票据原件。劳动争议仲裁委员会超期未作出受理决定证明书。张某遂诉至法院。

【案件焦点】

用人单位违法解雇孕期女职工致其社会保险费停缴，劳动者因此遭受的生育津贴损失应由用人单位负责赔偿。

【法院裁判要旨】

重庆市渝北区人民法院经审理认为：某科技公司因张某违反公司规章制度而辞退张某，但该公司并未举证证明张某存在违反公司规章制度的行为，故某科技公司构成违法解除，应支付违法解除劳动关系赔偿金。因张某选择要求某科技公司支付违法解除劳动关系赔偿金，不要求继续履行劳动合同，且张某工作期间的社会保险费已依法缴纳，加之张某未出示产生费用的证据原件，故对张某主张的生育津贴损失及生育生产费损失不予支持。

重庆市渝北区人民法院依据《中华人民共和国劳动法》第四十七条，《中华人民共和国劳动合同法》第四十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条之规定，判决如下：

- 一、某科技公司支付张某工资6766.5元；
- 二、某科技公司支付张某房屋销售佣金45102元；
- 三、某科技公司支付张某违法解除劳动关系赔偿金146160元；
- 四、驳回张某的其他诉讼请求。

张某不服一审判决，提起上诉。重庆市第一中级人民法院经审理认为：张某无法获得生育保险待遇系因某科技公司违法解除劳动合同后停缴生育保险费所致。孕期妇女在劳动合同解除后存在再就业的现实困境，如不能获得生育保险待遇，将丧失收入来源，不符合对女职工特别保护的立法本意。张某主张违法解除劳动合同赔偿金并不表明其放弃了对生育保险待遇损失。解除劳动合同赔偿金是法定的对用人单位违法行为的惩罚性赔偿，而生育保险待遇损失是劳动者非因自身原因在孕产期不能获得生育保险基金支付的各项费用的损失。两者并不竞合，可以一并主张。本案中，对于生育医疗费用，因张某未出示相关费用票据的原件，某科技公司对其真实性不予认可，且生育医疗费需要社保部

门进行核算，张某未举示社保部门核算后的具体费用组成，因此，二审对生育医疗费用不予支持。对于生育津贴损失，可根据《重庆市职工生育保险暂行办法》第十四条第三项规定，生育生活津贴=生育上年本人月平均工资÷30天产假工资×产假天数，该损失可以依法计算得出，故应予支持。

重庆市第一中级人民法院依据《中华人民共和国合同法》第四十二条、第四十八条，《女职工劳动保护特别规定》第七条，《重庆市人口与计划生育条例》第二十三条，《重庆市职工生育保险暂行办法》第十三条、第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、维持重庆市渝北区人民法院(2022)渝0112民初3508号民事判决第一项、第二项、第三项；

二、撤销重庆市渝北区人民法院(2022)渝0112民初3508号民事判决第四项；

三、由某科技公司向张某支付生育生活津贴损失57856元；

四、驳回张某的其他诉讼请求。

【法官后语】

用人单位违法解雇孕期女职工致其社会保险费停缴，劳动者能否同时主张用人单位支付赔偿金及生育保险待遇损失，实践中仍存在争议。《中华人民共和国合同法》第四十八条规定：“用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照本法第八十七条规定支付赔偿金。”据此，在用人单位违法解除劳动合同的情形下，是主张用人单位支付赔偿金还是主张复职，劳动者享有选择权。劳动者选择用人单位支付赔偿金，并不意味着其已放弃获得生育保险待遇的权利。

一、被解雇劳动者主张复职将面临的问题

对被解雇的劳动者而言，要求复职似乎是最全面和最彻底的救济方式。因为劳动者不仅可以继续在原岗位工作，维护职业安定，而且可以要求用人单位为其持续缴纳社会保险费。但劳动关系是一种人与人之间的关系，而不仅是合

同的或经济的关系。人与人之间关系的良好有效运作依赖于相互信赖和公平交易。要求复职对劳动者而言虽较为有利,但在劳动双方已经丧失信赖基础的情形下,多数劳动者仍会选择主张赔偿金。不仅如此,即使有部分劳动者主张复职并获得法院支持,复职判决也可能存在执行困难的问题。首先,劳动契约是一种继续性的契约关系,在其存续期间,劳动者的劳务给付义务和用人单位的工资支付、照顾等义务在合同期内非一次履行可以完结,需要反复进行。这样的强制履行,法院的监督成本过高。其次,劳动契约具有身份属性,劳动者身份上从属于用人单位,且履行劳动给付义务必须委身于用人单位的安排、管理、指挥和监督之下,如果用人单位故意将特定劳动者排除在管理体系之外,或者不提供劳动者完成劳动义务需要的客观条件,又或者拒绝受领劳动者提供的劳务,都会导致劳动者无法顺利地履行劳动合同约定的提供劳务的义务。因此,即使法院根据需要监督复职判决的执行,因为信息的不充分,也无法预见雇主对司法监督行为可能作出的反应,更无法阻止拥有充分信息的非善意雇主作出的与复职要求相反的逆向选择,从而达到倒逼劳动者自己离开企业的目的。

对于孕期女职工而言,要求复职相较于普通劳动者而言面临更多阻碍。用人单位违法解雇孕期女职工,多是为了降低用工成本。针对违法解雇行为,若孕期女职工坚持要求复职,非善意雇主为达到“甩包袱”的目的,往往会作出更多与复职要求相反的逆向选择,如撤销劳动者原来的工作岗位、改变劳动者的工作环境及工作强度等,以逼迫劳动者主动离职。因此,选择主张赔偿金是劳动者理性权衡后的结果,法律不能苛求孕期女职工为获取生育保险待遇而选择复职的救济方式。若以劳动者错误选择救济方式为由不支持劳动者主张的失业保险待遇损失,则相当于变相限制了劳动者选择权利救济方式的自由。

二、违法解雇赔偿金不能涵盖生育保险待遇损失

根据《中华人民共和国劳动法》第九十八条规定,用人单位违法解除劳动合同对劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。《中华人民共和国劳动合同法》第八十七条规定,用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应按经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。因此,用人单位违法解雇赔偿责任的支

付标准是法定的。但需注意的是,在我国法定的用人单位解雇责任中,不仅有违法解雇赔偿金,还有额外赔偿金、违法解雇期间的工资支付等多种责任形式。违法解雇赔偿金并非用人单位因违法解雇而唯一需要承担的责任。在用人单位违法解雇孕期女职工致其社会保险费停缴的情形下,用人单位支付的违法解雇赔偿金不能涵盖生育保险待遇损失。

首先,从违法解雇赔偿金的功能定位分析,违法解雇赔偿金是专门针对用人单位违法解雇行为而设立的,必然有意图遏制或约束用人单位违法行为发生之目的。实际上,对用人单位违法解雇行为(或不当解雇行为)进行制裁或惩罚也是世界上许多国家劳动立法的基本态度。若用人单位违法解雇孕期女职工所付出的成本与违法解雇其他员工所付出的成本相同,则会变相鼓励用人单位优先解雇孕期女职工,因为孕期女职工享有较长时间的带薪产假,同等条件下解雇孕期女职工更利于节省用工成本。这不仅与《中华人民共和国劳动合同法》设置违法解雇赔偿金的初衷相悖,也与《中华人民共和国妇女权益保障法》第二十六条规定的孕期女职工应受特殊保护的法律规定相冲突。

其次,从充分弥补劳动者损失的角度分析,劳动者受保护的范围不应低于普通民商事合同中的守约方。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。在平等民商事主体之间,一方违约给对方造成预期利益损失时尚需赔偿。在强调保护劳动者,尤其是孕期女职工权益的劳动法领域,更应确保用人单位对违法解雇行为给劳动者造成的预期利益损失承担赔偿责任。值得注意的是,有时违法解雇赔偿金甚至不足以弥补劳动者所遭受的生育津贴损失。如孕期女职工入职一年左右即遭用人单位违法解雇,其可获得的赔偿金金额为本人两个月工资。而根据《女职工劳动保护特别规定》第七条规定,女职工生育最低享受的产假天数为98天。地方政府可能会在前述规定的基础上增加产假天数。如《重庆市职工生育保险暂行办法》第十四条第一项规定:“女职工生

育产假为90天；晚育增加产假30天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天；难产增加产假15天。”即重庆地区妇女晚育产假天数可达到128天。即使按最低产假天数计算，劳动者应获得的生育津贴也会超过本人三个月的工资。若再加上生育医疗费用损失，则劳动者所遭受的损失将远超赔偿金金额。因生育保险待遇损失属于用人单位在实施违法解雇行为时应当预见到的损失，故应由用人单位承担相应赔偿责任。

本案中，张某主张的生育保险待遇损失由两部分组成：一是生育医疗费用；二是生育津贴。关于生育医疗费用，劳动者应举证证明其实际产生的金额及正常缴纳社会保险费情形下社会保险基金能够报销的比例。因本案劳动者未能举示充分有效的证据予以证明，故法院未予支持。关于生育津贴，因其计算标准是法定的，故法院予以支持。

编写人：重庆市第一中级人民法院 吴学文

七、劳务派遣

59

劳务派遣单位与劳动者是否 应签订无固定期限劳动合同的认定 ——某人力资源公司诉彭某劳动合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终9773号民事判决书

2. 案由：劳动合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某人力资源公司

被告(被上诉人):彭某

【基本案情】

2019年9月29日,彭某与某人力资源公司签订一年期劳动合同,合同中约定某人力资源公司将彭某派遣至某电信公司处从事营业代表工作。2020年9月27日、2021年10月20日,彭某与某人力资源公司先后两次对原劳动合同进行了续签,劳动合同期限分别为一年,彭某的岗位及双方权利义务均保持不

变。 彭某与某人力资源公司签订的第三份劳动合同到期后， 双方因未能达成一致意

见,未在第一时间对劳动合同予以续签。2022年11月1日,彭某停止在某电信公司处工作。同日,某人力资源公司向彭某邮寄《上岗报到通知书》,要求彭某于2022年11月2日到公司报到上岗,新岗位薪酬待遇不低于原岗位,若逾期未报到公司有权按有关规定处理。嗣后,彭某签收该通知书。2022年11月9日,某人力资源公司向彭某邮寄解除劳动合同书,该解除劳动合同书载明彭某在原用工单位退回后不愿意从事某人力资源公司推荐的工作岗位,双方协商未能就变更劳动合同内容达成协议,现双方根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十条第三项的规定解除劳动合同等内容。此后,该通知书被签收。

2023年5月8日,重庆市巴南区劳动人事争议仲裁委员会作出仲裁裁决:某人力资源公司向彭某支付违法解除劳动合同赔偿金50023元。某人力资源公司不服仲裁裁决,向法院起诉要求不支付彭某违法解除劳动合同赔偿金50023元。

【案件焦点】

某人力资源公司与彭某在连续签订两次劳动合同期满后是否必须签订无固定期限劳动合同。

【法院裁判要旨】

重庆市巴南区人民法院经审理认为:彭某与某人力资源公司已连续签订了两次固定期限劳动合同,故双方在再次续签劳动合同时,只要彭某未主动提出或者同意订立固定期限劳动合同的情况下,某人力资源公司应与彭某订立无固定期限劳动合同,某人力资源公司未经彭某同意,原则上不得变动彭某工作岗位。解除劳动关系不是唯一处罚方式,若只要违反规章制度就解除劳动关系,会造成劳动者行为的违规性与处罚不相当。某人力资源公司未举示证据证明其解除行为与适用法条合法,亦未举示其规章制度等证据,故其单方解除与彭某的劳动合同缺乏足够的事实依据和制度依据。

重庆市巴南区人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条、第四十七条、第八十七条,《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问

题的解释(一)》第三十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条之规定,作出如下判决:

一、某人力资源公司支付彭某赔偿金50023元;

二、驳回某人力资源公司的诉讼请求。

某人力资源公司不服一审判决,提出上诉。重庆市第五中级人民法院经审理认为:某人力资源公司与彭某建立的是劳务派遣合同关系,法律并未强制某人力资源公司须在两次劳动合同期满后与彭某签订无固定期限合同,是否续签为无固定期限劳动合同,应由双方协商一致决定。2022年9月30日双方劳动合同期满后,彭某仍在原用工单位、原岗位工作,视为彭某与某人力资源公司同意以原条件继续履行劳动合同,此时彭某与某人力资源公司之间属于事实劳动关系,双方均有权随时提出终止劳动关系。2022年10月27日,某人力资源公司通知彭某上岗报到且新岗位薪酬待遇不低于原岗位,但彭某收到通知后并未报到。某人力资源公司在劳动合同期满后欲提供不低于原岗位待遇的新岗位以维持劳动合同约定条件与彭某续订劳动合同,彭某收到该意思表示后既未报到亦未作出是否同意的意思表示,因此某人力资源公司解除双方劳动关系,无须向彭某支付经济补偿和经济赔偿金。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国劳动合同法》第四十四条、第四十六条、第五十八条、第六十六条第一款,《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十四条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

一、撤销重庆市巴南区人民法院(2023)渝0113民初14837号民事判决;

二、某人力资源公司无须向彭某支付经济赔偿金。

【法官后语】

劳务派遣用工是一种特殊的用工形式,不同于劳动合同用工。因劳务派遣实施在具有临时性、辅助性、替代性的工作岗位上,劳务派遣单位与劳动者通常不具有建立长期劳动关系的意向。虽然劳务派遣用工是被规制在劳动合同法大结构项下,劳动者与劳务派遣单位建立劳动关系,但该劳动关系是基于劳务

